



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário **0100188-08.2022.5.01.0024**

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 16/03/2022

Valor da causa: R\$ 14.188,40

Partes:

RECLAMANTE: ELISANGELA MENEZES DE OLIVEIRA DINIZ

ADVOGADO: fabia de Moraes lopes silva

RECLAMADO: HOSPITAL MAHATMA GANDHI

ADVOGADO: LEONARDO SODER MACHADO FONTENELE

ADVOGADO: PAMELA JESUS DA SILVA MOREIRA BOTELHO

ADVOGADO: GABRIELA GOMES SILVA DA ROCHA

RECLAMADO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
24ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro
ATOrd 0100188-08.2022.5.01.0024
RECLAMANTE: ELISANGELA MENEZES DE OLIVEIRA DINIZ
RECLAMADO: HOSPITAL MAHATMA GANDHI, ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SENTENÇA

ELISANGELA MENEZES DE OLIVEIRA DINIZ ajuíza reclamação trabalhista em face de HOSPITAL MAHATMA GANDHI, ESTADO DO RIO DE JANEIRO , pelos fatos e fundamentos expostos em sua inicial, instruindo-a com documentos.

Respondem as reclamadas com documentos, impugnando os pedidos, requerendo a sua improcedência.

Conciliação recusada.

Alçada fixada no valor da inicial.

Encerrada a instrução processual, inconciliáveis .

FUNDAMENTAÇÃO.

DAS PRETENSÕES

Os fatos são incontroversos a respeito da injusta dispensa e nada foi pago ao trabalhador e não obstante as alegações de que não houve repasse dos valores que lhes são devidos em decorrência da crise econômica oriunda da pandemia, de lege lata, trata-se de risco do negócio que toca ao empregador, com base no art .2º da CLT.

De tal sorte, são devidas as seguintes parcelas, conforme indicadas no TRCT id. a4c547b, Saldo de salario de 01 dias R\$ 1.422,17 décimo prop 11 /12 ; R\$ 2.522,91 férias vencida 12/2020 a 12/2021 R\$ 2.728,74 ;1/3 férias vencidas R\$ 909,58 ;

Paga a destempo, procedem as multas dos arts. 467 e 477, ambos da CLT, incidindo a primeira sobre todas as verbas discriminadas no termo de rescisão contratual.

Por inexistir comprovação do seu recolhimento , procede o pedido de pagamento da multa de 40 % a incidir sobre a totalidade dos valores de FGTS devidos.

Deferida a tutela antecipada para liberação da guias de FGTS, bem como a expedição de ofício para habilitação no Seguro Desemprego.

Indeferido o requerimento de expedição de mandado de bloqueio e pagamento para a Secretaria Estadual de Saúde , nos termos da tese vinculante fixada na ADPF nº 485 ("Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)").

Da responsabilidade subsidiária da 2ª ré .

A 2ª ré não nega que tenha sido beneficiária dos serviços da parte reclamante.

Não se questiona, no presente caso , a legalidade do contrato de gestão havida entre as rés.

É efetivamente o que ocorreu na hipótese dos autos, haja vista que as partes reconhecem que existe contrato de gestão realizado entre a 1ª e a 2ª rés na área da saúde, para execução na UPA de BANGU, bem como que existe contrato entre a real empregadora da parte reclamante e a 1ª ré com vistas à prestação de serviços em favor da 2ª ré.

O artigo 818, da CLT, prevê a possibilidade do juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

Diante dos limites traçados na lide é evidente a condição da hipossuficiência do trabalhador, o que justifica a redistribuição dinâmica do ônus da prova, sendo que a jurisprudência não discrepa desse entendimento, conforme Súmulas 41 e 43 desse E. Tribunal:

Responsabilidade subsidiária

da

Administração Pública. A constitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 71 da Lei 8.666/93, declarada pelo STF no julgamento da ADC nº 16, por si só, não afasta a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, quando esta decorre da falta de fiscalização. No julgamento do RE nº 760.931, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese, com repercussão geral: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". O exame da ratio decidendi da mencionada decisão revela, ainda, que a ausência sistemática de fiscalização, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora, autoriza a responsabilização do Poder Público. Após o julgamento dos embargos de declaração e tendo sido expressamente rejeitada a proposta de que fossem parcialmente acolhidos para se esclarecer que o ônus da prova desse fato pertencia ao empregado, pode-se concluir que cabe a esta Corte Superior a definição da matéria,

diante de sua natureza eminentemente infraconstitucional. Nessa linha, a remansosa e antiga jurisprudência daquele Tribunal: AI 405738 AgR, Rel . Min. Ilmar Galvão, 1ª T . , julg. Em 12/11/2002; ARE 701091 AgR, Rel . Min. Cármen Lúcia, 2ª T . , julg. Em 11/09 /2012; RE 783235 AgR, Rel . Min. Teori Zavascki, 2ª T . , julg. Em 24 /06/2014; ARE 830441 AgR, Rel (a) Min. Rosa Weber, 1ª T . , julg. em 02/12/2014; ARE 1224559 ED-AgR, Relator (a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019. Portanto, em sede de embargos de declaração , o Supremo Tribunal Federal deixou claro que matéria pertinente ao ônus da prova não foi por ele definida, ao fixar o alcance do Tema 246. Permitiu, por conseguinte que a responsabilidade subsidiária seja reconhecida, mas sempre de natureza subjetiva, ou seja, faz-se necessário verificar a existência de culpa in vigilando . Por esse fundamento e com base no dever ordinário de fiscalização da execução do contrato e de obrigações outras impostas à Administração Pública por diversos dispositivos da Lei nº 8.666/1993, a exemplo, especialmente, dos artigos 58, III; 67, caput e seu § 1º; e dos artigos 54, § 1º; 55, XIII; 58, III; 66; 67, § 1º; 77 e 78, é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços. No caso, o Tribunal Regional consignou que os documentos juntados aos autos pelo ente público são insuficientes à prova de que houve diligência no cumprimento do dever de fiscalização, relativamente ao adimplemento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizada. Ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. A Egrégia Turma, por sua vez, atribuiu ao trabalhador o ônus da prova, razão pela qual merece reforma a decisão embargada, a fim de restabelecer o acórdão regional. Recurso de embargos conhecido e provido.

Do exposto, não existe qualquer prova acerca da fiscalização do contrato de prestação de serviços pela tomadora; razão pela qual é deferida a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada ao pagamento de todos os parcelas deferidas nesta sentença por todo período do contrato da parte reclamante, sem exceção.

Deferida a gratuidade da justiça ao autor , por preenchidos os requisitos do art. 790, § 3º, da CLT.

Indeferida a gratuidade de justiça e a isenção das contribuições previdenciárias à 1ª ré por não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, não tendo a ré apresentado qualquer documento que comprove suas alegações.

Tendo em vista a procedência dos pedidos, são devidos honorários de sucumbência, em favor da parte reclamante, à razão de 10 % sobre o valor líquido da condenação, considerando-se a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 791-A, §2º, CLT).

ISTO POSTO resolve a 24ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO, decidir pela **PROCEDÊNCIA DO PEDIDO**, para condenar as reclamadas a satisfazerem a pretensão do reclamante conforme postulada em sua inicial, **sendo a 2ª ré de forma subsidiária**, deduzidas todas as parcelas pagas sob idênticos títulos, a fim de não gerar enriquecimento sem causa e na forma da fundamentação que a este decisum integra para todos os efeitos legais.

Oportunamente serão deduzidas a cota previdenciária e a alíquota do imposto de renda, respeitados os sujeitos passivos na forma da legislação vigente, cuja responsabilidade na retenção e recolhimento é da ré, observado a Lei 8.541/92 e Provimento CGJT n. 3/84 e alterações posteriores (OJ 228 da SDI -I do TST).

Juros e correção monetária na forma da decisão do STF, Pleno, ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.12.2020.

Custas de R\$ 283,77 sobre R\$ 14.188,40, valor arbitrado à condenação, pela ré.

Intimem-se.

RIO DE JANEIRO/RJ,

RAPHAEL FERRARI GOLDBERG

RIO DE JANEIRO/RJ, 04 de dezembro de 2023.

JOSE HORTA DE SOUZA MIRANDA

Juiz do Trabalho Titular



Assinado eletronicamente por: JOSE HORTA DE SOUZA MIRANDA - Juntado em: 04/12/2023 19:26:22 - 3dee0b0
<https://pje.trt1.jus.br/pjekz/validacao/23112914122711400000189702660?instancia=1>
Número do processo: 0100188-08.2022.5.01.0024
Número do documento: 23112914122711400000189702660